

1501107-85.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes - não consta a data do trânsito em julgado para a Defesa - fls. 31-21 (autos 1501144-49.2021.8.26.0599).

Entao, cuida-se de pessoa que se envolve em práticas criminosas, em especial, a do tráfico de drogas.

Portanto, não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

As ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501107-85.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199876/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 26311439 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2199876 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 25 dias do mês de outubro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel. Apresentados o acusado GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Marcos Antonio dos Santos Júnior e Kallel Christianini Barbosa..

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Marcos e Kallel) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES como como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nodia 24 de julho de 2022, por volta de 19h35min, na Rua Pascoal Barsotini, altura do n. 255, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES, qualificado e indiciado às fls. 06, agindo em conluio e com identidade de designios delituosos com pessoa não identificada, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 11 (onze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2,7g (dois gramas e sete decigramas), e 06 (seis) porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 8,4g (oitogramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares notaram o denunciado e uma pessoa não identificada comportando-se de forma suspeita como aproximação da viatura (um deles gritou “moio polícia”). O denunciado foi abordado. A pessoa que o acompanhava evadiu-se. No bolso de GUSTAVO, os policiais encontraram quatro eppendorfs com cocaína e R\$105,75 (cento e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Nas imediações, em um muro, mais sete pinos idênticos com cocaína e seis porções de maconha. Aos policiais, o denunciado assumiu o tráfico de drogas. Na Delegacia, ficou em silêncio.

Diante das circunstâncias da prisão, da apreensão de dinheiro, da quantidade e forma de embalagem, é certo que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

Auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo pericial de fls. 16-18 E 91-93.

DA FASE JUDICIAL - PROVA ORAL

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - PM - narrou que estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico. Uma pessoa gritou “moio, polícia”. Na sequência, ele correu e não foi abordado. O réu estava na esquina, subindo e quando aquela pessoa gritou “moio, polícia”, o réu mudou a direção e passou a caminhar em sentido oposto. Ele ia em direção à viatura e mudou a direção. O réu foi abordado. No short, na parte traseira, encontrou quatro pinos de cocaína e moedas. Na cintura, havia notas diversas de dinheiro. Em cima de um muro, encontrou mais porções de entorpecentes. O muro ficava próximo, cerca de dez metros do local da abordagem. O réu estava sozinho. Havia pessoas em um ponto de ônibus, mas não tinham contato com o réu. No início ele negou, mas depois confessou o tráfico de drogas dizendo que precisava de dinheiro. As porções do muro eram iguais às encontradas com o réu. Com relação à pessoa que gritou e fugiu, o réu nada falou.

No mesmo sentido, KALLEL CHRISTIANINI BARBOSA - PM.

O réu disse que tinha ido ao local para comprar drogas. Comprou um salgado na padaria e quatro pinos. Não ouviu ninguém gritar “molhou, polícia”. Estava indo embora quando foi abordado. Falou para os policiais que tinha acabado de comprar drogas.

NÃO HÁ DÚVIDAS

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009). Há de se considerar que o réu disse aos policiais que estava

traficando drogas. É até possível que a pessoa que gritou e fugiu também estivesse envolvida no tráfico, mas o que não se pode desconsiderar é que as drogas em poder do réu eram iguais as do muro e aos policiais, o réu disse que estava traficando. Considerando a quantidade, diversidade e forma de embalagem das drogas, é certo que o réu a trazia consigo e guardava para fins de comércio.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: " A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011). Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10) Considerando as circunstâncias da abordagem, a considerável quantidade e sua forma de embalagem é possível afirmar que a droga se destinava ao comércio ilegal.

Da dosimetria da pena

O réu é primário.

Folha de antecedentes e certidões nos autos: GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES possui condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes - não consta a data do trânsito em julgado para a Defesa - fls. 31-21 (autos 1501144-49.2021.8.26.0599).

Então, cuida-se de pessoa que se envolve em práticas criminosas, em especial, a do tráfico de drogas.

Portanto, não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

As circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

E mais, cabe destacar que o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas instituiu o denominado tráfico privilegiado a prestigiar o princípio da individualização da pena, tendo por objetivo diferenciar as penas impostas ao traficante eventual e àquele que habitualmente se dedica à atividade criminosas.

E nessa seara, após longa discussão doutrinária e jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, reconheceu

que a figura do “tráfico privilegiado de drogas”, contida no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, não ostenta natureza hedionda, sendo, posteriormente, acompanhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar o enunciado de sua súmula nº 512.

O privilégio tem o condão de diminuir a pena de um a dois terços e demanda a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam, a i) primariedade e ii) e bons antecedentes do agente, a iii) não dedicação a atividades criminosas e, por fim, iv) não integração de organização criminosa. Na ausência de um destes elementos inviabiliza-se o reconhecimento da causa de diminuição.

No tocante ao requisito da dedicação a atividades criminosas, tem-se que alguns fatores podem denotar habitualidade e envolvimento no crime, impedindo o reconhecimento da figura privilegiada.

Exemplo disso é a constatação de que o réu tinha grande quantidade e diversidade de drogas.

Ora, as circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

É o que permite o art. 42 da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n.º 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Gustavo de Oliveira Lopes foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls.64-65), no dia 24 de julho de 2022, por volta de 19h35, na Rua Pascoal Barsotini, altura do n.º 255, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES, agindo em conluio e com identidade de designios delituosos com pessoa não identificada, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 11 (onze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2,7g (dois gramas e sete decigramas), e 06 (seis) porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 8,4g (oito gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda conforme a inicial acusatória, policiais militares notaram o denunciado e uma pessoa não identificada comportando-se de forma suspeita com a aproximação da viatura (um deles gritou "moio polícia"). O denunciado foi abordado. A pessoa que o acompanhava evadiu-se. No bolso de GUSTAVO, os policiais encontraram quatro eppendorfs com cocaína e R\$105,75 (cento e cinco reais e setenta e cinco centavos). Nas imediações, em um muro, mais sete pinos idênticos com cocaína e seis porções de maconha. Aos policiais, o denunciado assumiu o tráfico de drogas.

Auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo pericial de fls. 16-18.

Na delegacia o policial militar Marcos Antonio Dos Santos Junior disse que:

"Realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, um deles gritou "moio polícia", fato que ensejou sua abordagem para averiguação; Um deles logrou fuga, sendo que o segundo foi abordado e identificado como Gustavo De Oliveira Lopes, com o qual, nos bolsos, foram encontrados 4 pinos tipo eppendorf contendo substância aparentando cocaína, bem como a importância de R\$105,75; Indagado, o abordado inicialmente negou a propriedade das drogas, contudo, depois acabou afirmando que tentava ganhar algum dinheiro com a venda das drogas; Em buscas realizadas, sobre um muro ali existente, encontraram mais 7 pinos idênticos bem como 6 porções de substância esverdeada, aparentando maconha, individualmente embaladas, de forma comumente utilizada para o tráfico" (fls. 3-4).

No mesmo sentido, as declarações do policial militar Kallel Christianini Barbosa (fl. 5).

Interrogado em solo policial, disse: "Que nega a prática do delito que lhe é atribuído pelos policiais militares; Que é usuário de drogas; Que não está machucado, não tendo sofrido qualquer tipo de agressão, seja física ou psicológica, antes ou depois de sua prisão" (fl. 6).

As fls. 31-32, juntadas folha de antecedentes e certidão de objeto e pé que indicam a reincidência do requerido (1501144-49.2021.8.26.0599, art. 33, LD, audiência admonitória em 22/06/2022).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de fls. 91-93.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvido inicialmente o policial militar Marcos Antonio Dos Santos Junior. Relatou que a equipe estava em patrulhamento no local conhecido como ponto de tráfico. Um indivíduo que conseguiu fugir gritou "Moio, polícia". O réu foi abordado. Ele estava na esquina, subindo. Na hora em que o indivíduo gritou, ele virou o sentido que caminhava, desceu em sentido oposto ao da viatura. Na busca pessoal, no shorts, na parte traseira, encontraram 4 "pinos" identificados como cocaína e moedas. Na cintura, encontraram notas diversas. Na vistoria do local, em cima do muro, encontraram mais algumas porções de entorpecentes. O muro ficava próximo ao local em que foi abordado, por volta de 20 metros. O muro era de esquina, no local onde o

réu foi abordado. O muro ficava na rua Pascoal Barsotini, ao lado do ponto de ônibus. A droga que estava no muro era a mesma droga encontrada com Gustavo (mesma cor do eppendorf). Gustavo estava sozinho quando foi abordado. Havia pessoas do ponto de ônibus, que não tinham contato com ele. Gustavo, no começo, negou. Depois, teria confessado a traficância por precisar de dinheiro. Não conhecia o réu. O réu nada disse sobre a pessoa que gritou e saiu correndo. Essa pessoa também estava nas imediações.

Em seguida, ouvido o policial militar Kallel Christianini Barbosa. Informou que estava em patrulhamento no local dos fatos e ouviu alguém gritar “moio, polícia”. Havia alguns indivíduos próximo ao ponto de ônibus. O local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Não conseguiram abordar a pessoa que gritou. As pessoas dispersaram. Abordaram o réu, que subia a rua e, ao ouvir o aviso, mudou de direção. Gustavo estava próximo aos indivíduos que dispersaram. Há um ponto de ônibus em que as pessoas ficam sentadas, caminhando, subindo a rua. Os indivíduos que estavam no ponto subiram a rua. Gustavo mudou de rumo quando a pessoa gritou, por isso suspeitaram. Gustavo não estava junto com os demais indivíduos. O restante do pessoal já tinha subido. Fizeram a busca. No bolso de trás da bermuda encontraram 4 pinos de cocaína e moedas. na linha da cintura, havia mais R\$99,00 em notas diversas. A equipe, em busca na localidade próxima, na parte de cima de um muro, encontrou porções de maconha e cocaína – estas idênticas às porções que estavam com ele. O muro era próximo de onde Gustavo foi abordado, de 5 a 10 metros. De início, Gustavo negou a traficância. Depois, confessou, dizendo que precisava “levantar um dinheiro”. Gustavo não portava objeto para uso de drogas. Não conhecia o réu.

Por fim, interrogado o acusado Gustavo de Oliveira Lopes. Estava com R\$150,00 em dinheiro. Passou na padaria, comprou um salgado por R\$5,00. Saiu da padaria e foi ao ponto de tráfico, que fica na esquina, perto da padaria. Depois, foi ao ponto de tráfico, comprou 4 porções de cocaína. O dinheiro era proveniente do trabalho como servente. Tinha recebido o dinheiro na sexta-feira. Um rapaz na esquina vendeu a droga. Pagou R\$10,00 cada pino de cocaína. Estava indo embora para casa quando a polícia chegou. Os policiais lhe abordaram e lhe prenderam. Não sabe dizer quem gritou, não ouviu. Estava indo embora quando os policiais chegaram, não mudou de direção. Falou para os policiais que tinha acabado de comprar a droga e era para o seu consumo. Falou que comprou de um rapaz de bicicleta. Esse rapaz já tinha saído do local. Os policiais não foram atrás dessa pessoa. O restante da droga não era seu. Não sabe dizer de quem era. Não conhece os policiais e não tem nada contra.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Eventual sentença de condenação estaria embasada nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto

não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

Com Gustavo foram localizadas apenas 4 porções de cocaína. O réu confessou que é usuário da droga, e que estava no local – que é um ponto de tráfico – para adquirir o entorpecente. Adquiriu a droga das pessoas que ali estavam e gritaram quando a polícia se aproximou. Tinha aproximadamente R\$150,00, adquiridos com o seu trabalho como servente de pedreiro. Comprou as 4 porções de drogas por R\$10,00/cada. O dinheiro que tinha consigo era o troco da compra da droga e de um salgado. Conforme relatou a polícia, havia outras pessoas no local, quem gritou “moio, polícia” não foi Gustavo, e o réu não foi visto em atos de traficância. Tudo isso faz com que não haja certeza quanto à traficância, uma vez que Gustavo contou estar no local para adquirir a droga encontrada em seu poder.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, “No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho “Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos”, de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína.” (p. 8-9 do Acórdão)”.

É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida do acusado não é excessiva, corroborando as declarações do acusado no sentido de que é usuário.

Isso posto, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: “A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais” (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não tendo sido demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

“PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo” (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição, tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional por ferir o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: “Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]” (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344). Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: “O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, fixada tal premissa, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal

no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas. Isso posto, diante da alegação ora invocada, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, afastando-se a imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas, o que torna imperiosa a sua absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Porém, rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, a reincidência deve ser compensada com a atenuante da menoridade de 21 anos.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c. o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 24 de julho de 2022, por volta de 19h35, na Rua Pascoal Barsotini, altura do nº 255, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos com pessoa não identificada,

trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 11 (onze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2,7g (dois gramas e sete decigramas), e 06 (seis) porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 8,4g (oito gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares notaram o réu e uma pessoa não identificada comportando-se de forma suspeita com a aproximação da viatura (um deles gritou "moio polícia").

O réu foi abordado. A pessoa que o acompanhava evadiu-se.

No bolso de Gustavo, os policiais encontraram quatro eppendorfs com cocaína e R\$105,75 (cento e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Nas imediações, em um muro, mais sete pinos idênticos com cocaína e seis porções de maconha.

Aos policiais, o réu assumiu o tráfico de drogas. Na delegacia, ficou em silêncio. Diante das circunstâncias da prisão, da apreensão de dinheiro, da quantidade e forma de embalagem, é certo que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 63), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 67/68).

O réu foi notificado (fls. 79) e apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 83/85).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 94/97). O réu foi citado (fls. 116).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa do crime de tráfico está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 12, na fotografia de fls. 15, no laudo de constatação de fls. 17/18 e no exame químico-toxicológico de fls. 92/93, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína e Tetrahidrocannabinol (THC), nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos. Vejamos.

Na fase investigativa, o réu afirmou que passavam pelo local, quando foi abordado por policiais militares, os quais encontraram drogas próximo de onde estava, sendo então conduzido sob acusação de estar traficando. Não praticou o delito que lhe é atribuído pelos policiais militares. É usuário de drogas (fls. 06).

Em Juízo, o réu disse que estava com R\$ 150,00 em dinheiro, passou na padaria para comprar um salgado e desceu até o ponto de venda para comprar 04 pinos de droga. Depois que comprou a droga, foi abordado pelos policiais e levado à Delegacia. O dinheiro era proveniente do seu trabalho de servente. Tinha recebido o dinheiro da sexta-feira. Saiu da padaria com o salgado na mão. Pagou R\$ 5,00 pelo salgado. A padaria fica perto do ponto de venda de drogas, que fica bem na esquina, perto da padaria. Tinha um rapaz na esquina, de bicicleta, que lhe vendeu 04 pinos de cocaína, pelo preço de R\$ 10,00 cada um. Estava indo embora para casa, quando os policiais o abordaram. Não ouviu ninguém gritar "moio, polícia". Estava indo embora e não mudou de direção. Falou aos policiais que a droga era para seu próprio consumo, que tinha acabado de adquiri-la de um rapaz de bicicleta. O moleque de bicicleta saiu andando de bicicleta. Os policiais não foram atrás do moleque de bicicleta. O restante da droga não era dele. Faz uso de cocaína e consegue ficar sem consumi-la.

A autoria foi corroborada pelas demais provas existentes nos autos. Vejamos.

O policial militar Marcos Antônio dos Santos Júnior relatou que estavam em patrulhamento em local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram um indivíduo correr e gritar: "moio, polícia". Não conseguiram abordá-lo. O réu

estava na esquina, subindo a rua. Quando a pessoa gritou, o réu virou-se e passou a caminhar em sentido oposto. Ele estava caminhando em direção à viatura e, depois do grito, virou-se. Abordaram o réu e, no shorts, na parte traseira, encontraram 04 pinos de cocaína e algumas moedas. Na cintura dele, havia notas trocadas. Na vistoria do local, em cima do muro, encontraram mais drogas. O muro ficava a 10 metros de onde o réu foi abordado. O muro fica na esquina na rua Pascoal Barsonite. A droga encontrada no muro tinha a mesma cor daquela encontrada com o réu. O réu estava sozinho, mas havia pessoas no ponto de ônibus, sem contato com o réu. No começo, o réu disse que a droga era para uso, mas depois confessou que estava precisando de dinheiro e, por isso, vendia drogas. Não conhecia o réu. O réu nada disse sobre a pessoa que gritou e correu. A pessoa que gritou estava nas imediações.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Kallel Christianini Barbosa, que asseverou que estavam em patrulhamento e acessaram a rua descrita na denúncia. Desciam a rua e, próximo ao ponto de ônibus, avistaram alguns indivíduos. Quando se aproximaram, um dos indivíduos gritou “moio, polícia” e saiu. O réu estava próximo do ponto de ônibus, subindo. De imediato, o réu, que estava caminhando, virou-se e começou a subir. O réu não estava junto com o indivíduo que gritou. Somente o réu foi abordado. Em busca pessoal, encontrou 04 pinos de cocaína e moedas no bolso de trás da bermuda e no elástico da cueca havia mais R\$ 99,00 em notas diversas. Em busca nas proximidades, encontraram mais alguns pinos idênticos àqueles que estavam com o réu e algumas porções de maconha, sobre um muro. O réu foi abordado de costas para o muro e de 5 a 10 metros do local da abordagem, estava o restante da droga, em cima dele. O réu foi indagado e negou a situação, mas depois acabou confessando, dizendo eu precisava “levantar” um dinheiro. Não havia objeto para uso de drogas, com o réu. Não conhecia o réu. O local é conhecido como ponto de venda de drogas.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial negou a posse de qualquer entorpecente. Em Juízo, ele aduziu que estava na posse de 04 porções de cocaína, que tinha acabado de adquirir, por R\$ 40,00, de um rapaz de bicicleta. Negou que o restante da droga lhe pertencesse.

Já os policiais militares narraram que realizavam patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram alguns indivíduos, um dos quais que, ao notar a presença da viatura, gritou “moio, polícia”. Em razão desses fatos, foram abordá-los, mas essa pessoa que gritou conseguiu correr e aqueles que estavam com ele se separaram. O réu que subia a rua, no entanto, quando ouviu o grito da Polícia, virou-se e passou a descer a rua, o que motivou sua abordagem e, em revista pessoal, no seu bolso, os policiais encontraram 04 microtubos de cocaína, bem como R\$105,75 em dinheiro. Indagado, o réu inicialmente negou a propriedade das drogas, contudo, depois acabou confirmando que tentava ganhar algum dinheiro, com a venda das drogas. Em buscas nas proximidades, os policiais encontraram, sobre um muro ali existente, mais 07 microtubos de cocaína, idênticos àqueles apreendidos em poder do réu, além de 06 porções de maconha.

Nesse sentido, temos duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, que nega qualquer envolvimento com a droga apreendida em cima do muro, e a dos policiais militares, no sentido de que 04 porções de cocaína foram apreendidas no bolso do réu e o restante nas proximidades.

Considerando que o local é ponto de venda de drogas e que o terceiro que não foi identificado gritou, avisando da aproximação da viatura, fica claro que estava ocorrendo atividade ilícita.

De outro lado, havia com o réu parte da droga, exatamente idêntica àquela que estava homiziada no muro.

De outro lado, a alegação do réu de que tinha acabado de adquirir drogas de um elemento de bicicleta não encontra respaldo nos autos, porque os policiais informaram que não havia ninguém perto do réu e nada mencionaram a respeito de algum elemento de bicicleta indicado pelo réu.

De mais a mais, se fosse abordado após a aquisição da droga, o réu teria

imediatamente apontado o vendedor, pessoa que poderia ser abordada pelos policiais, contudo, aos policiais, o réu nada disse sobre isso.

Por fim, a cocaína em poder do réu e a encontrada em cima do muro estava embalada da mesma forma, confirmando que tinham a mesma origem.

Nesse sentido, da forma como ocorreu a abordagem, entendo que a versão dos policiais merece confiança.

De outra banda, a palavra dos policiais militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial, como no presente caso, quando corroborada com a apreensão da droga.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Ressalto que os agentes não tinham motivo para prejudicar o réu.

Comprovado o envolvimento do réu com toda a droga, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo

37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu negou a posse de qualquer entorpecente, afirmando ser somente usuário. Contudo, a prova confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas.

Os policiais estavam realizando patrulhamento de rotina, em ponto de venda de drogas, quando notaram terceiro não identificado comportando-se de forma suspeita, já que, com a aproximação da viatura, gritou "moio polícia".

Com o aviso do elemento não identificado, o réu alterou sua direção, demonstrando que estava na prática de ilícito.

A quantidade de entorpecente não era expressiva, no entanto, as situações da sua localização afastam a alegação do consumo próprio, porque o réu estava na posse de 04 porções de cocaína e, sobre o muro, nas proximidades, havia mais 07 microtubos de cocaína, idênticos àqueles encontrados com o réu, além de 06 porções de maconha. É comum que o traficante permaneça com pouco entorpecente e guarde o restante escondido nas proximidades, exatamente para dificultar a ação policial e afastar a responsabilidade pelo delito mais gravoso.

Além da droga, com o réu havia dinheiro trocado (fotografia de fls. 15), cuja procedência lícita não foi comprovada. Note-se que o réu afirmou que tinha recebido R\$ 150,00 dois dias antes, pelo serviço de servente de pedreiro que prestou, contudo, inexistiu nos autos qualquer comprovação desse trabalho remunerado.

Por fim, aos policiais, informalmente, o réu confessou a prática delitiva.

Assim, a quantidade e qualidade da droga, além de sua forma de embalagem, a apreensão de dinheiro, a confissão informal do réu; tudo revela que a droga na posse da ré tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma